

1500947-58.2021.8.26.0417
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR
Comarca: Paraguaçu Paulista
Foro: Foro de Paraguaçu Paulista
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 17/02/2022
... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VICTOR GAVAZZI CESAR

Vistos.

ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na noite de 04 de novembro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paraguaçu Paulista
Foro de Paraguaçu Paulista
3ª Vara
Avenida Siqueira Campos, 1429, . - Vila Affine
CEP: 19700-000 - Paraguacu Paulista - SP
Telefone: (18)3361-2844 - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

1500947-58.2021.8.26.0417 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500947-58.2021.8.26.0417
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VICTOR GAVAZZI CESAR

Vistos.

ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na noite de 04 de novembro de 2021, por volta das 18h10min, na rua Said Mohamed Euaf nº 335, neste município e comarca de Paraguaçu Paulista, teria trazido consigo, guardado e

mantido em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 8,72kg de maconha, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e laudo de constatação provisória da droga (fls. 21/23).

O acusado foi devidamente notificado (fls. 78) e apresentou defesa prévia (fls. 102/112).

Recebida a denúncia, procedeu-se à instrução processual, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão acusatória, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, apontando para a fragilidade do acervo probatório e sustentando existência de causa excludente de ilicitude. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação de delito ou, ainda, a fixação da pena em patamares mínimos, fazendo remissiva à Defesa Prévia de fls. 102/112.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do réu ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ pela prática dos fatos narrados na denúncia.

Registre-se, de início, que processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas.

Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada.

Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

O "caput" do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas ao comércio e a movimentação substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o objeto jurídico é a saúde pública.

Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/08/2015).

No mérito, a pretensão acusatória deve ser julgada integralmenteprocedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 03, pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelos laudos periciais de fls. 23/25, 74/76 e 93/95, bem como prova oral colhida.

A autoria também é certa, recaindo de forma inarredável sobre o réu. Vejamos.

Em sede policial, o réu ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ permaneceu em silêncio (fls. 07).

Ao ser interrogado em juízo, o réu confirmou a ocorrência dos fatos narrados na inicial. Afirmou, no entanto, que tudo ocorreu em uma segunda-feira. Acordei, fui trabalhar e, por volta das 18h, voltei para casa. Então, recebi a visita de um rapaz, a quem devia R\$ 3.000,00 (três mil reais). Ele chegou em casa me ameaçando, caso eu não o pagasse essa dívida. Eu não tinha dinheiro porque já havia gastado com o pagamento da pensão alimentícia de minha filha e com a pintura do meu carro. Ele, então, me fez uma proposta. Entregou uma caixa preta e um saco preto, que eu deveria guardar e não mexer. Eu fui trabalhar normalmente na quinta-feira. Esse indivíduo ainda me incumbiu de levar uma sacola, com uma caixa de sapato preta que ele me entregou, conforme ele me indicaria. Se assim o fizesse, quitaria a minha dívida. No dia, fui realizar essa entrega e, ao chegar ao local apontado, me deparei com o mesmo carro que havia sido utilizado pelo indivíduo para ir até a minha residência levar os sacos. O carro me deu um sinal de luz. Na ocasião, acabei sendo abordado por duas viaturas policiais. Na fuga, capotei o carro e a droga acabou sendo localizada no interior do meu veículo. Confessei aos Policiais que, em minha residência, havia somente um "baseado" na estante. Me separei de minha esposa e tive uma recaída. Por isso, acabei usando drogas e pegando esse dinheiro emprestado. O mesmo carro que foi até a minha residência levar os sacos me deu um sinal de luz no dia da minha prisão. Era a mesma pessoal. Na hora, falei que era uma "mulher" para os Policiais, mas, na verdade, se tratava do mesmo rapaz que foi me ameaçar em casa, caso eu não pagasse minha dívida. O rapaz disse que iria até a minha casa retirar o restante da droga em outra oportunidade. Não acompanhei as buscas feitas pelos Policiais em meu imóvel. Permaneci com o reforço da Policial no local do capotamento. O imóvel era, de fato, minha residência. Como eu havia me separado, havia poucos móveis no local. Todos as drogas e petrechos estavam dentro do saco preto, fechado, e a ordem era para eu não mexesse. Tenho 21 anos de idade. Nunca tive nenhuma passagem pela polícia e sempre trabalhei como pedreiro, desde pequeno. Passei a usar cocaína e, em razão do vício, acabei criando essa dívida, chegando ao montante de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Pagava pensão alimentícia todo o dia 20. Sem pensar, acabei tomando essa atitude. Nunca fui traficante, sempre fui trabalhador.

Na fase inquisitiva, as testemunhas JOÃO ALEX FLOR NOGUEIRA e MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS, Policiais Militares, afirmaram que "durante patrulhamento tático pela área deste Município, avistaram dois veículos parados na entrada da cidade, mais precisamente no início da avenida do "Autoposto Trucks". De imediato, um tentou empreender fuga, no que decidiram pela abordagem, logrando seguir no encalço do veículo VW/Gol, cinza placas CSY-1F93, o qual, após alguns minutos de acompanhamento, veio a adentrar na SP-284, sentido cidade de Assis, sendo que ao ganhar uma vicinal de chão batido, perdeu o controle da direção, vindo a chocar-se com o barranco e capotar. Foi, então, retirado do veículo seu único ocupante,

identificado como Ismael de Oliveira José, o qual nada de ilícito portava, bem como do acidente suportado não sofreu nenhuma lesão física. Estava consciente e orientado, não sendo necessário socorro médico. Iniciada revista no interior do auto, lá estava um tijolo da erva tida por maconha, além de outros dois pedaços da mesma substância entorpecente. Estava muito nervoso. Perguntado sobre mais substância entorpecente, afirmou que tinha em sua residência, assim diante do estado flagrancial, se deslocaram até a residência, no momento, sem demais pessoas, e procederam buscas, tendo o depoente localizado onze tijolos de maconha, embalados da mesma forma e material do localizado no auto em questão. Ainda, em buscas pela residência, localizou cinco rolos de plástico transparente, plástico esse que embalavam todos os tijolos que apreenderam nessa ocorrência. O depoente localizou, ainda, uma balança de precisão, uma faca com resquícios da mesma substância entorpecente e uma talhadeira, tudo devidamente apreendido, denotando claramente que aquele ambiente era usado para embalar, comercializar e guardar drogas”.

No curso da instrução processual, os referidos Policiais Militares foram novamente inquiridos, corroborando integralmente o teor dos depoimentos prestados na fase de Inquérito.

Consignaram, ainda, que no momento da abordagem, um Gol Branco, que não foi identificado, conseguiu se evadir do local. Após o réu ser perseguido, houve o capotamento do seu veículo, sendo as primeiras porções de entorpecentes localizadas dentro de uma caixa de sapatos, no interior do automóvel. Posteriormente, o restante foi localizado no interior de sua residência, cujas buscas foram acompanhadas pelo genitor do réu. Os 11 tijolos de droga, além dos rolos de plástico filme, balança de precisão e faca, estavam escondidos embaixo da pia da cozinha. No momento da abordagem inicial, nos aproximamos dos veículos e acionamos os sistemas sonoro e luminoso, ocasião em que os carros imediatamente iniciaram marcha e se evadiram. Tivemos que optar por perseguir apenas um veículo, no caso, o Gol cinza conduzido pelo réu, que estava mais “fácil” de ser alcançado. Em conversas com o réu, ele disse que morava com os pais no condomínio Viena. Posteriormente, caiu em contradição e informou que a família tinha um outro imóvel em que ele estaria residindo atualmente e que era utilizando para esconder mais drogas. No momento em que nos dirigimos ao local apontado, o genitor do réu chegou junto com a guarnição, franqueou nossa entrada e confirmou que seu filho estava morando no imóvel. A casa pertencia à família. Todos os itens apreendidos estavam embaixo da pia. No local, havia poucos móveis, mas havia uma cama e outros eletrodomésticos básicos para a sobrevivência. Alguém deve ter avisado o genitor do réu sobre a nossa chegada. No momento da prisão, Ismael admitiu a traficância e esclareceu que a pessoa que havia se evadido do local no momento da abordagem, em um Gol branco, tratava-se de uma mulher que havia ido ao seu encontro para comprar entorpecentes.

Encerrada a instrução, restou comprovado, de forma segura, que o réu efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, tal como descrito na denúncia.

Restou devidamente comprovado que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na peça exordial, Ismael trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, 8,72kg de “maconha”, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela cidade de Paraguaçu Paulista, quando avistaram dois veículos parados na entrada do município, próximo ao “Autoposto Trucks”. Ao notarem a aproximação da viatura policial, os ocupantes dos veículos imediatamente empreenderam fuga do local.

Ocorre que o ocupante do veículo VW/Gol, de placas CSY-1F93, não logrou êxito em

seu intento, sendo imediatamente perseguido pelos agentes de segurança. Ocorre que, durante a fuga, o réu perdeu o controle do seu carro, vindo a capotá-lo.

No local do capotamento, os policiais militares identificaram o réu Ismael como sendo o único ocupante do veículo e, ao efetuarem buscas em seu interior, localizaram um tijolo de "maconha" e mais dois outros pedaços grandes da aludida substância entorpecente, ocasião em que o denunciado confessou informalmente a prática do tráfico e o armazenamento de mais drogas no interior de sua casa.

Ante a situação de flagrância, os policiais militares se dirigiram até a residência apontada pelo réu, ocasião em que localizaram outros onze tijolos de "maconha", embalados da mesma forma como o material encontrado no interior do veículo, além de petrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e rolos do plástico filme, todos devidamente apreendidos.

Tais conclusões decorrem dos depoimentos prestados de forma uníssona e coerente pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, anotando-se que as palavras dos agentes públicos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Nada há nos autos a indicar que os Policiais quisessem deliberadamente prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de um crime desta natureza, até mesmo porque nem ao mesmo se conheciam ou nutriam entre si alguma espécie de animosidade pretérita.

Frise-se que os Policiais gozam de presunção de legitimidade no tocante aos atos decorrentes do exercício da função que desenvolvem, garantindo normal credibilidade aos seus depoimentos.

Ressalte-se, neste contexto, que não existe dispositivo legal que vede aos agentes policiais servirem como testemunhas. Além disso, não se pode presumir que os agentes de segurança, empossados que são, após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de incriminar inocentes.

Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente. A atuação dos agentes públicos revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado.

Seria verdadeiro um contrassenso o Estado conferir-lhes atribuição para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse qualquer crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a reavaliação probatória. 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido" (HC 262.582/RS,

Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).

“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira fase da dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado para o fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos” RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA (TJSP; Apelação 0020225-91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018).

Por outro lado, embora o réu tenha negado a prática do crime de tráfico, a versão por ele apresentada não encontra qualquer respaldo nos demais elementos de convicção e provas, ficando isolada quando em cotejo com restante do acervo constante dos autos.

Percebe-se, nesse sentido, que o réu foi incapaz de infirmar o restante do conjunto probatório, que lhe é contrário, não apontando motivos aptos motivar a prova oral colhida ao longo da instrução, deixando de oferecer justificativa plausível para os fatos narrados ou, ainda, apontar eventuais equívocos nas provas materiais produzidas.

A versão apresentada em juízo - de que teria contraído uma dívida de R\$ 3000,00 (três mil reais) com um traficante não identificado, que repentinamente o teria obrigado a guardar entorpecentes no interior de seu imóvel, restituindo parcela deles dias depois - não convence, revelando-se mera tentativa de o réu furtar-se de suas responsabilidades.

Nota-se que, além da grande quantidade de entorpecente apreendido, também foram localizados no interior de sua residência, conforme bem demonstra o auto de apreensão de fls. 12/13 e fotografias de fls. 26/35, diversos outros petrechos diretamente relacionados com o fracionamento e preparo da droga para venda - como rolos de plástico filme, balança de precisão, facão e talhadeira, que contava com resquícios da substância ilícita - o que reforça a ausência de verossimilhança do relato prestado pelo réu em seu interrogatório.

Ainda, os próprios Policiais Militares, que sequer conheciam Ismael de outras ocorrências, apontaram que no momento da prisão, o réu imediatamente confirmou a propriedade da droga, esclarecendo que a pessoa que havia conseguido se furtar da abordagem policial, tratava-se de uma mulher que havia ido ao seu encontro para adquirir entorpecentes, restando bastante evidente o seu envolvimento direto com a espúria mercancia.

No mais, a apreensão da droga no interior do imóvel ocorreu de forma lícita, não havendo que se questionar qualquer eventual ilegalidade quanto à violação do domicílio do representado.

A teor do art. 5º XI da CF/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Da interpretação do referido dispositivo constitucional, decorre que o ingresso no domicílio do representado seria admitido em três situações, qual seja, I) Se

houvesse autorização judicial para tanto; II) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador; III) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local.

Ademais, a jurisprudência já reconheceu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04 e 05/11/2015 - repercussão geral - Noticiada no informativo 806).

Conforme se infere da prova produzida nos autos, o ingresso no imóvel foi amparado em fundadas razões, considerando que o réu, após tentar se evadir da guarnição policial durante regular ação regular de patrulhamento, acabou sendo alcançado e preso em flagrante na posse de um tijolo de maconha e duas outras porções consideráveis de maconha, localizado no interior de seu veículo.

Em razão da prisão e do estado flagrancial, o réu acabou confessando aos Policiais que guardava e armazenava mais entorpecentes no interior de sua residência, impondo-se, a partir do conjunto de tais circunstâncias, a continuidade da ação policial para pôr termo à prática criminosa de natureza permanente.

Assim, de rigor reconhecer a licitude da atuação policial, não havendo máculas aptas a inquiná-la.

Por fim, após a realização de perícia definitiva nos entorpecentes apreendidos (fls. 93/95), confirmou-se tratar de 14 (quatorze) porções, com massa líquida de 8,72 quilograma(s), de substância contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante da lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 135 de 03/08/2020).

A grande quantidade de entorpecentes, somada às demais circunstâncias do evento (prisão em flagrante no momento da entrega de entorpecentes à terceiros e apreensão de outros petrechos diretamente relacionados ao fracionamento, preparo e embalagem da droga para posterior comercialização), evidenciam que as drogas apreendidas em posse do réu realmente se destinavam ao proscrito comércio.

Ademais, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Além do mais, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil ao acusado.

Do mesmo modo, não há como acolher as teses defensivas, que pugnam pelo reconhecimento de estado de necessidade, coação moral ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação.

Isso porque, conforme já bem delineado no bojo desta fundamentação, não há nenhuma prova nos autos que sustente minimamente a ocorrência de tais eventos, sendo certo que o réu agiu na exata forma como descrito na denúncia, executando, de forma livre e consciente, os verbos nucleares do tipo penal incriminador.

No mais, a despeito da primariedade do agente, entendo incabível a incidência da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 ("tráfico privilegiado"), porquanto a grande quantidade de entorpecente apreendida revela que o acusado também se dedica a atividades criminosas.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida com o réu não é usualmente confiada a traficantes neófitos, a revelar a recalcitrância na prática espúria, o que impede a aplicação da benesse acima mencionada, conforme atesta o aresto abaixo colacionado:

"APELAÇÃO - Tráfico ilícito de entorpecentes - Materialidade e autoria demonstradas. Apelante preso em flagrante, pois, em concurso com adolescente, trazia consigo maconha. Validade dos depoimentos dos policiais e testemunha presencial - Grande quantidade a evidenciar que o destino era a espúria mercancia e que se dedicava a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06" (TJ/SP; Apelação 0010787-80.2009.8.26.0032; Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 23/10/2012).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, a atenuação da pena e do regime prisional. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes. Guarda e depósito de entorpecentes configuram infração permanente, induzindo situação de flagrante delito, hipótese em que se permite a entrada na residência do suspeito sem mandado judicial. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria comporta reparos. Basilar deverá ser fixada no mínimo, sob pena de indevido bis in idem, eis que a quantidade e diversidade de entorpecentes justificaram o afastamento do privilégio. Impossível a concessão do redutor. Não preenchimento dos requisitos legais (TJ-SP - APR: 15003544320208260165 SP 1500354-43.2020.8.26.0165, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 11/05/2021, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021)

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA APREENSÃO (...) Não incidência do redutor, tendo em vista a grande quantidade, acondicionamento, variedade, natureza da droga apreendida, além das circunstâncias que cercaram o flagrante, a indicar que não se trata de traficância inédita que pudesse qualificar os embargantes como "traficantes de primeira viagem" ou "pequenos traficantes" (o que comercializa pequena quantidade de drogas apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), mesmo porque não se obtém tal monta, variedade e tipo de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia tal quantidade de drogas a alguém que não tenha alcançado o mínimo de envolvimento dentro da cadeia do tráfico. Embargos infringentes rejeitados (TJ-SP - EI: 00212674820188260050 SP 0021267-48.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 09/09/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2020)

Além disso, a prova produzida nos autos indica que o próprio réu atuava diretamente na comercialização dos entorpecentes - guardando e tendo em depósito, no interior de sua residência, grande quantidade de drogas; na sequência, fracionando e preparando para venda e consumo de terceiros; finalmente, providenciando sua venda e entrega para o consumidor.

Tais condutas se distinguem, sobremaneira, daquelas praticadas por pequenos traficantes iniciantes ou, ainda, pelas conhecidas "mulas do tráfico", indivíduos que são pontualmente cooptados em situação de vulnerabilidade econômica para

realizarem o transporte de drogas para traficantes experimentados ou organizações criminosas, e que acabam presos em suas primeiras incursões pelo mundo criminoso, sem qualquer indicativo de habitualidade ou integração à organizações criminosas.

Cioso registrar que “a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes” (STJ - HC 510077/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no HC 507910/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019), circunstância que não se verifica na espécie.

Assim, havendo prova segura de que o réu, embora primário, se dedicava às atividades criminosas, de rigor o afastamento do privilégio.

Conclui-se, portanto, que o acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo, motivo pelo qual deve ser responsabilizado penalmente por sua conduta.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 5º, da Constituição Federal e ao critério trifásico estatuído no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima) anoto que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim, levando-se em conta a ausência de circunstâncias desabonadoras a serem avaliadas nessa fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de valorá-la, considerando que a pena já se encontra fixada no patamar mínimo (Súmula 231/STJ).

Na terceira fase, denota-se a ausência de causa de aumento de pena. Pelas razões já expostas, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (“tráfico privilegiado”), considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Assevero a quantidade de entorpecentes não foi sopesada na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista “a necessidade da valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida deve ser feita em apenas uma das fases do cálculo da pena, vendando-se bis in idem” (STF: Repercussão Geral – Temas 712 - ARE 666.334/AM).

Deste modo, “natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem”, em respeito ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp 1484629/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019; AgRg no HC 497047/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, 14/05/2019, DJe 25/06/2019)

Assim, torno definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no piso (1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do crime), pois não há elementos suficientes nos autos para aferir a capacidade econômica do réu. (artigos 49, §1º e 60, ambos do CP).

Levando-se em consideração o quantum de pena fixado e a quantidade considerável de entorpecentes apreendidos, entendo que o regime adequado para o início de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

A respeito do tema, a jurisprudência reconhece que “o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga” (HC 492114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no REsp 1799931/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, especialmente o quantum de pena fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ISMAEL DE OLIVEIRA JOSÉ, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, com a unidade no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Considerando a inexistência de alterações fáticas que recomendem sua revogação, permanecem incólumes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do réu (artigos 312 e 313 do CPP), motivo pelo qual nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, §1º do CPP.

Expeça-se certidão de honorários.

Proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/06, caso ainda não tenha ocorrido, com as cautelas de praxe.

Decreto a perda dos bens (veículo apreendido e utilizado para a prática do tráfico) e valores eventualmente apreendidos nos autos em favor da União.

Após o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, nos termos do art. 686, do CPP.
- b) Oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação;
- c) Oficie-se ao TRE, para os fins do inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal;
- d) Expeçam-se as guias e ofícios necessários para a execução das penas impostas.
- e) Cumpridas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Paraguacu Paulista, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA